

RECURSO CÍVEL Nº 5061953-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. FOLGA INDENIZADA. "DIAS DE FOLGA INDENIZADA". "DIAS DE DOBRA". "INDENIZAÇÃO DE TREINAMENTO (FOLGA)". "FERIADOS". SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. DISTINÇÃO ENTRE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FOLGA NÃO GOZADA E O PAGAMENTO DOBRADO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VERBAS DISTINTAS. A "DOBRA OFF SHORE" NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES ISENTIVAS DO IRPF, NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI N.º 7.713/88. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO LABORAL, NOS TERMOS DO ART.43, DO CTN. DELIMITAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A FOLGA INDENIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, mantendo a sentença de parcial procedência, nos termos da fundamentação supra. Condene a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2024.

5061953-65.2024.4.02.5101

510014915611 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5061953-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

"DISPOSITIVO.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para:

a. RECONHECER, nos termos da fundamentação supra, o direito do autor de não ser compelido ao recolhimento de Imposto de Renda referente aos valores percebidos sob as rubricas de "DIAS DE FOLGA INDENIZADA" e "INDENIZAÇÃO TREINAMENTO (FOLGA)".

b. RECONHECER o direito do autor de ser restituído dos valores indevidamente recolhidos a título de "Folgas Indenizadas", observando-se o prazo prescricional quinquenal, contado retroativamente a partir da data de ajuizamento da presente demanda, em 16/08/2024, e a incidência da Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios por força do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995."

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que "a sentença recorrida acertadamente reconheceu a natureza indenizatória das dias de folga indenizada e indenização treinamento (folga), afastando a incidência do imposto de renda sobre tais verbas. No entanto, ao manter a tributação sobre as rubricas "dobras" e "feriados", incorreu em equívoco que merece ser corrigido". Aduz, ainda, que "as "dobras" e os "feriados" visam compensar o

trabalhador pelos dias de folga não gozadas e pelos feriados trabalhados durante o período de folga, respectivamente". Alega que as rubricas "dobras" e "feriados" possuem natureza indenizatória. Requer, portanto, que todos os pedidos sejam julgados procedentes

Contrarrazões apresentadas pela União em Evento 22.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

O cerne da questão está em determinar a natureza dos pagamentos feitos à parte autora.

Veja-se o teor do art. 43 do CTN:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

§ 2º Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Os valores devidos em virtude de folgas não gozadas são de natureza indenizatória.

A lógica que se apresenta é a seguinte: estando o trabalhador à disposição do empregador no momento em que deveria estar liberado, há uma supressão de possibilidade de descanso ou de realização de atos outros importantes à sua vida. Qualquer acréscimo realizado à quantidade de tempo que o trabalhador deva permanecer no trabalho é um cerceamento de tempo que poderia ser utilizado ao arbítrio do trabalhador.

É por tal razão que é indenizatória a natureza de pagamentos devidos em função de férias e/ou folgas não gozadas. A natureza indenizatória de tais pagamentos, por sua vez, impede a incidência de imposto de renda sobre os valores adquiridos, por não haver real acréscimo patrimonial, ao contrário do que alega a ré em sede recursal, mas mera indenização por serviços prestados e pela supressão de possibilidades pela qual passou o autor.

No mesmo sentido compreende o STJ, através de precedentes:

TRIBUTÁRIO. VALORES RECEBIDOS COMO COMPENSAÇÃO DE FOLGAS NÃO USUFRUÍDAS NA OPORTUNIDADE DEVIDA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA NÃO-INCIDÊNCIA. I - Sendo o agravado empregado da PETROBRÁS, o regime de trabalho é o estabelecido na Lei nº 5.811/72, que regula o trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração e produção de petróleo. Como tal, o trabalho é exercido em regime de revezamento e de sobreaviso, regulado na aludida lei. II - Na hipótese de alteração do regime de trabalho por iniciativa do empregador, seria assegurado ao empregado o direito à percepção de uma indenização (art. 9º). Com o advento da CF/88 houve redução da jornada de trabalho dos petroleiros, ante o disposto no inciso XIV do art. 7º ("jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva"). III - Se a empregadora, por dificuldades operacionais, não promoveu a imediata alteração do regime de trabalho de seus empregados, o que veio a ocorrer apenas em agosto de 1990, e, para acertar o regime de descanso não gozado, ou das ditas folgas, no período entre a promulgação da CF/88 e a data da alteração do novo regime de trabalho, foi acertado com a empregadora que esta pagaria uma indenização, (aquela prevista no art. 9º da Lei nº 5.811/72), pelos períodos de descanso não usufruídos oportunamente, esses valores correspondiam à indenização das folgas não gozadas, por necessidade do empregador, em vista do sistema de turnos que foi implantado pela empresa. IV - Em situação como a presente, este Tribunal vem entendendo não ser possível a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos como compensação das folgas não usufruídas na oportunidade devida. Precedentes: REsp nº 728.376/RN, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 19/03/2007; REsp nº 865.729/SE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 03/10/2006; REsp nº 781.980/RN, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 03/04/2006; REsp nº 502.197/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 29/08/2005; e AGREsp nº 669.155/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 28/03/2005. V - Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 979.765/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 19/12/2007, p. 1182)

Ainda, a Súmula 125 do STJ:

"O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda."

Por fim, a TNU, no PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200, julgado em 16/03/2020, firmou a seguinte tese:

"Não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas".

Por sua vez, a folga indenizada não se confunde com a dobra, devida aos trabalhadores em regime *off-shore* que é expressamente tratada pelo artigo 2º, da Lei 5.811/72, nos seguintes termos:

Art. 2º Sempre que for imprescindível à continuidade operacional, o empregado será mantido em seu posto de trabalho em regime de revezamento.

§ 1º O regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas será adotado nas atividades previstas no art. 1º, ficando a utilização do turno de 12 (doze) horas restrita às seguintes situações especiais:

a) atividades de exploração, perfuração, produção e transferência de petróleo do mar;

b) atividades de exploração, perfuração e produção d áreas terrestres distantes ou de difícil acesso.

§ 2º Para garantir a normalidade das operações ou para atender a imperativos de segurança industrial, poderá ser exigida, mediante o pagamento previsto no item II do art. 3º, a disponibilidade empregado no local de trabalho ou nas suas proximidades, durante o intervalo destinado a repouso e alimentação.

O referido dispositivo prevê que é possível a manutenção do empregado no posto de trabalho sempre que foi imprescindível para a continuidade da operação, prevendo a lei acima em seu artigo 3º alguns direitos dentre eles o pagamento em dobro e o direito a um repouso de 24 horas consecutivas para cada 3 turnos trabalhados, conforme abaixo:

Art. 3º Durante o período em que o empregado permanecer no regime de revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes direitos:

*I - Pagamento do adicional de trabalho noturno na forma do **art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho**;*

II - Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida nos termos do § 2º do art. 2º;

III - Alimentação gratuita, no posto de trabalho, durante o turno em que estiver em serviço;

IV - Transporte gratuito para o local de trabalho;

V - Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 (três) turnos trabalhados.

Analisando a redação da legislação acima, conclui-se que o momento de folga perdida pela dobra é compensada com outra folga posterior, havendo apenas um adiamento. Ante isso, os valores recebidos pela dobra tem natureza remuneratória.

Assim, em razão do trabalhador em regime *off-shore* poder ser mantido no posto de trabalho em período que seria de descanso, por necessidade da empresa de continuidade do serviço operacional ou por segurança, será devido ao empregado o pagamento diferenciado por cada hora trabalhada, além do repouso compensatório em período subsequente, nos termos da Lei 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho em atividades relacionadas à exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização de xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados.

Contudo, é preciso bem estabelecer que o valor a maior pago pelas horas trabalhadas pagas em período de descanso possui natureza remuneratória, sujeitando-se, portanto, à incidência de imposto de renda e apenas a indenização pelo descanso não fruído é que tem natureza indenizatória.

Desta forma, existe dupla repercussão na manutenção do marítimo no posto de trabalho: por um lado, o recebimento de verba decorrente das horas trabalhadas em dobro, em valor superior à hora de trabalho normalmente paga fora do período de descanso, que representa acréscimo patrimonial. Do outro, o pagamento de indenização em separado pela renúncia ao direito ao descanso, para executar o trabalho determinado pelo empregador, não incidindo imposto de renda neste último caso.

Vale ressaltar que independente da nomenclatura dada à verba pelo empregador na convenção/acordo coletivo(a) de trabalho, a mesma não se impõe ao Fisco, uma vez que as convenções particulares não são hábeis a modificar a legislação tributária, retirando a responsabilidade do contribuinte de efetuar o recolhimento do tributo, seja imposto de renda ou mesmo contribuição previdenciária, conforme dispõe o artigo 123 do CTN.

Especificamente em relação ao imposto de renda no caso em tela, a tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título, conforme dispõe o artigo 3º, §4º da Lei nº 7.713/88.

Assim, a renda auferida pela parte autora, uma vez identificada como fato gerador de imposto de renda, previsto no artigo 43 do CTN, incidirá o referido tributo, independente do *nomen iuris* atribuído no contracheque ou contrato de trabalho pelo empregador.

Além disso, não há como conferir interpretação extensiva de que todas as verbas recebidas pela parte autora, a título de trabalho fora da jornada, configuram indenização, devendo ser verificadas as efetivas naturezas das mesmas, já que a legislação tributária, no casos de benefício fiscal, utiliza-se a interpretação restritiva, nos termos do artigo 111, inciso II, do CTN.

Por derradeiro, conferir entendimento diverso ao exposto acima, é atribuir de forma absurda o papel de legislador à empresa contratante, onde ficaria a cargo desta definir o nome da verba e sua natureza, impactando conseqüentemente todo o sistema tributário nacional, que por óbvio, além de interferir na arrecadação do imposto de renda, esbarraria na incidência de outros tributos, tais como a contribuição previdenciária, gerando um colapso fiscal.

Superada a distinção de folgas e dobras, o trabalho pré-embarque também não se confunde com folga indenizada. Segundo entendimento dos Tribunais Regionais do Trabalho, o trabalho pré-embarque é considerado como tempo à disposição do empregador e deve ser pago a título de hora extra trabalhada.

HORAS EXTRAS. TEMPO À DISPOSIÇÃO. As horas que o empregado fica aguardando embarcar na aeronave, quer plataforma, quer em hotel devem ser pagas como extras, pois o empregado ficava à disposição da empresa, sem poder usufruir do tempo como lhe conviesse, o qual era suprimido não de suas horas de trabalho, mas sim de repouso. (TRT-1 - RO: 0010090-23.2014.5.01.0067 RJ, Relator: GISELLE BONDIM LOPES RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2017, Sétima Turma, Data de Publicação: 19/03/2018)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 463. O enunciado sumular prevê que os valores recebidos a título de indenização por hora extra sofrem a incidência do imposto de renda.

Súmula 463

Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.

Por fim, somente estarão no campo da não-incidência do tributo sobre a renda as verbas que reflitam a conversão em pecúnia do descanso subsequente não usufruído, a exemplo das "folgas indenizadas", "folga trabalhada", "indenização de folga", excluídas desse contexto as demais rubricas pleiteadas inicialmente, as quais não se incluem no critério legalmente erigido para fins de não incidência de tributação - a natureza indenizatória propriamente dita, sem cunho de acréscimo patrimonial (art. 43, I e II, e §1º do CTN), ao menos pelas mesmas razões assim definidas quanto às folgas indenizadas.

Desse modo, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não merece ser acolhida a pretensão autoral de não incidência do imposto de renda sobre as rubricas "dobras" e "feriados". Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido, processo de nº 5001090-74.2023.4.02.5103/RJ, desta Relatoria, julgado por unanimidade na Sessão Ordinária do dia 20/03/2024.

Ante o exposto, voto por **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, mantendo a sentença de parcial procedência, nos termos da fundamentação supra. Condene a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.